

1501540-72.2022.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/09/2022
... Data de Registro: 06/07/2022).

CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501540-72.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501540-72.2022.8.26.0540
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MOISÉS MARCOLINO DOS SANTOS e outro

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

EZEQUIEL LOPES DA CONCEIÇÃO e MOISÉS MARCOLINO DOS SANTOS foram denunciados por incursão no inciso II do § 2º e no inciso I do § 2º-A, ambos do artigo 157 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia no dia 09 de agosto de 2022, por volta das 20h30min, na Avenida Vitório Brisante, 700, Jardim Zaira, na comarca de Mauá, os denunciados, agindo de em concurso entre si e com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo em face da vítima Marta Aparecida de Souza, subtraíram, em proveito comum, o seu veículo FIAT/MOBI LIKE, placas EFC0G401, e o seu aparelho celular Samsung Galaxy M12.

Recebida a denúncia, os réus foram citados (fls. 131-2) e apresentaram resposta à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, procedeu-se ao interrogatório dos réus.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa busca a absolvição ante a insuficiência de provas ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, com o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa de Moisés, a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo, além da fixação de regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-5), boletim de ocorrência (fls. 14-8), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 29), auto de exibição e apreensão (fls. 30-1), auto de reconhecimento de objeto (fl. 32) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Os réus Moisés e Ezequiel foram devidamente interrogados em solo policial e sob o contraditório (fls. 12-3 e mídia digital). Em juízo, admitiram o envolvimento no delito, mas procuraram eximir-se da utilização de armas de fogo, afirmando terem feito uso de um único simulacro (mídia digital).

A vítima Marta, na fase antejudiciária, narrou que (sic) "foi assaltada na hora e local dos fatos, mais especificamente por volta das 20h e 30min, na Rua Vitória Brisante, 708, Bairro Zaíra, Mauá/SP quando tinha acabado de estacionar o veículo FIAT MOBI LIKE, branco, ano 2019, de placas EFC0G40, e de repente três indivíduos apareceram anunciando assalto mediante grave ameaça com arma de fogo, ocasião em que levaram o veículo e seu celular Galaxy M12, bem como documentos e cartões de banco, tendo posteriormente acionado a PM. Logo após, foi acionada pela polícia militar, que informou ter localizado seu veículo, e comparecendo na delegacia, reconheceu em razão das características físicas, EZEQUIEL LOPES DA CONCEIÇÃO e MOISÉS MARCOLINO DOS SANTOS, como sendo dois dos autores do roubo, bem como reconhecendo o carro e celular como sendo seus" (fl. 11).

Durante a instrução, confirmou que estava descarregando compras do carro, quando foi abordada por três indivíduos usando máscara, dois deles armados. Logo depois do roubo, soube que a polícia localizou o seu veículo próximo a uma academia e que os suspeitos bateram o carro. Na delegacia, estava muito nervosa e não foi capaz de reconhecer os autores do delito (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do Min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que "todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas" (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

Os policiais militares, em solo policial, historiaram que (sic) "estavam em patrulhamento por volta das 21h, quando foram acionados via COPOM sobre ocorrência que acabara de acontecer, qual seja, roubo a veículo ocorrido por volta das 20h e 30min, na Rua Vitória Brisante, 708, Bairro Zaíra, Mauá/SP. Assim, diligenciaram pelas redondezas e quando trafegavam pela Rua Guerino Stela, nº10, Zaíra, Mauá/SP visualizaram transitando na referida rua o veículo roubado, qual seja, FIAT MOBI

LIKE, branco, ano 2019, de placas EFC0G40, e ao efetuarem a abordagem lá estavam dois indivíduos, posteriormente identificados como o Sr. GUILHERME ROSSI FARIAS conduzindo o veículo, bem como MOISÉS MARCOLINO DOS SANTOS, no banco do passageiro. Assim, na revista pessoal nada de ilícito encontraram, e após a leitura dos direitos constitucionais, GUILHERME afirmou que estava na academia "ESTAÇÃO10", localizada em frente ao local da abordagem, tendo entrado por volta das 19h e ficado até umas 21h, e quando estava perto de sair um senhor desconhecido pediu ajuda na academia para ligar um carro, visto que estava com problemas, assim ajudou a ligar o carro, porém percebeu que o solicitante de prenome MOISÉS não sabia dirigir direito, assim, questionou de quem era o carro, tendo MOISÉS afirmado que era do seu pai, e que morava no "MACUCO", desse modo se ofereceu para levar o carro até a casa do seu pai, e logo em seguida sofreu a abordagem. Já MOISÉS disse que de fato é um dos autores do roubo do veículo abordado, juntamente com "EZEQUIEL" apelidado de "QUIEL", bem como por outro indivíduo de prenome "DANIEL", e que foi convidado pra fazer o "corre", sendo que após o assalto, acabaram por bater o carro, momento em que EZEQUIEL e DANIEL fugiram. Ao ficar sozinho solicitou ajuda na academia, momento em que um rapaz depois identificado como GUILHERME se disponibilizou pra ajudar, e logo após sofreram a abordagem, declarando ainda que sabia o endereço do comparsa "EZEQUIEL", qual seja, Rua João Campos, 628, Bloco 01, apt 26, Jardim Olinda, Mauá/SP. Diante da informação apresentada realizaram nova diligência no endereço mencionado pelo autor do roubo, e ao se aproximarem da residência do segundo autor, denominado "EZEQUIEL", observaram um indivíduo pulando o muro para fora do condomínio, ocasião em que realizaram a abordagem identificando-o como EZEQUIEL LOPES DA CONCEIÇÃO, estando ele na posse de um celular, Modelo Galaxy M12, provavelmente proveniente da conduta ilícita praticada anteriormente. Igualmente, esclarecido sobre seus direitos constitucionais, afirmou que de fato praticou o roubo ao veículo FIAT MOBI juntamente com Moisés, e outro indivíduo desconhecido, conhecido pelo apelido de "cabeção" (fls. 06-7 e 09-10).

Em juízo, o policial militar Jonas reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido. Disse que, após ter sido irradiado o roubo do veículo Fiat/Mobi, iniciaram patrulhamento pelas proximidades e visualizaram o carro transitando em via pública com dois ocupantes, Guilherme na direção e Moisés no banco do passageiro. Efetuaram a abordagem e nada de ilícito foi encontrado com eles. Apurou-se que Guilherme estava em uma academia e apenas auxiliou Moisés a conduzir o veículo. O réu Moisés, por sua vez, de pronto admitiu a participação no roubo junto com outros dois indivíduos, Ezequiel e Daniel, os quais fugiram após uma colisão. Moisés, ainda, informou o endereço de Ezequiel, onde ele foi visto tentando fugir. Procederam à abordagem e dentro da cueca do suspeito foi apreendido o telefone celular da vítima. Informalmente, Ezequiel também confessou a prática delitiva. Por fim, acrescentou que a prisão dos acusados ocorreu aproximadamente dez minutos após o roubo. Na Delegacia, a vítima reconheceu os acusados (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres

Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Ao final da instrução, restou comprada a autoria dos réus.

Embora a vítima não tenha reconhecido os acusados em juízo, evidente que Moisés e Ezequiel estavam envolvidos no delito, já que foram presos em flagrante logo depois do roubo, na posse dos bens subtraídos da vítima, um deles com o veículo e o outro com o celular.

As majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo foram comprovadas pela prova oral colhida, notadamente a palavra da vítima.

Registre-se, respeitado entendimento em contrário, ser dispensável a apreensão da arma de fogo, quando existentes outros meios aptos a comprovar sua efetiva utilização. Nessa linha: STJ, HC 29.346-SP, DJU 13.10.2003. Nesse sentido:

"(...) A majorante do emprego de arma de fogo também restou devidamente configurada pelas palavras das vítimas. Independentemente de a arma de fogo não ter sido apreendida, o reconhecimento dessa causa de aumento é de rigor, já que ela pode perfeitamente ser comprovada pela prova oral, no caso, a palavra das vítimas, que narraram que um dos réus portava arma de fogo durante a ação. É nesse sentido que se posiciona o Superior Tribunal de Justiça (...)" (TJSP; Apelação Criminal nº 0013449-58.2017.8.26.0348, Relator: ALEX ZILENOVSKI; Julgado em 9 de março de 2022).

Além disso, o recrudesimento do roubo praticado com arma de fogo, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, não é inconstitucional por afronta ao princípio da proporcionalidade. É evidente a maior periculosidade dos indivíduos que praticam roubos com a utilização de arma de fogo, razão pela qual é necessária sanção mais rigorosa. Sobre o tema:

"Em que pese a alongada manifestação lançada pela Defensoria Pública, não se constata "vício" com relação à hipótese prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, fruto da alteração legislativa promovida pela Lei nº. 13.654/2.018, que estipulou aumento de dois terços (2/3) de pena diante do roubo praticado com emprego de arma de fogo. Nesse tom, a forma "majorada" estampada no verbete em destaque traduz a preocupação do legislador em punir de forma mais severa aqueles que se utilizam do artefato para vencer por completo a capacidade de resistência das vítimas, não se ignorando, ademais, que a prévia aquisição do instrumento demanda maior grau de planejamento e preparação por parte dos criminosos, além de o objeto expor a perigo concreto a integridade física das vítimas e de terceiros, tudo justificando o maior rigor conferido pelo legislador, atento ao princípio constitucional da proporcionalidade. No caso, impossível se ignorar o acentuado potencial vulnerante da arma de fogo frente aos demais artefatos que também delineavam a majorante prevista no revogado artigo 157, § 2º, I, daquele Estatuto Repressor, os quais voltaram a ser contemplados no inciso VII do verbete em destaque com o advento do "Pacote Anticrime" (Lei nº 13.964/2.019) que, inclusive, referendou a distinção de tratamento diante do roubo cometido mediante emprego de armas brancas e daquele perpetrado com artefatos explosivos ou armas de fogo. Outro não é o entendimento desta Colenda Câmara sobre o tema ao lembrar o óbvio: "... o intuito do legislador, com a promulgação da Lei nº 13.654/18, foi punir mais gravemente o roubo praticado com o emprego de arma de fogo (e com razão, diante da violência urbana incontrollável que assola e macula a sociedade ordeira, situação para a qual o Estado não pode fechar os olhos), sendo estrábica para não dizer de má-fé qualquer alegação tendente a sugerir sua ineficácia" (TJESP, Apelação Criminal nº. 1501374-45.2018.8.26.0228, Relator Desembargador ZORZI ROCHA, julgado 10-10-2019). Ainda a respeito, "a diferença de tratamento trazida pela Lei n. 13.654/2018 se amolda ao princípio da proporcionalidade, eis que pune, de forma mais rigorosa, o delito cometido com emprego de arma de fogo, diferentemente do

praticado com outras armas. Ora, o emprego de arma de fogo, para ameaçar a vítima, aumenta a probabilidade de dano à integridade física e à vida do ofendido e de outras pessoas, bem como facilita a execução do crime. Desta forma, a conduta deve ser punida de forma proporcional à sua gravidade" (TJESP, Apelação Criminal nº. 0036696-55.2018.8.26.0050, Relator Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 21-03-2019). No mais, convém notar que o Egrégio Órgão Especial desta Corte se manifestou sobre a higidez do processo legislativo e constitucionalidade formal do diploma alterador (Incidente de Inconstitucionalidade sob o nº. 0017563-80.2018.8.26.0000, Relator Desembargador ALEX ZILENOVSKI, julgado 05-09-2018), sem em nenhum momento sinalizar eventual vício capaz de obstaculizar a aplicação da norma por este Egrégio Tribunal. E as "comparações" entre tipos/conduas feitas pela Defesa, de tão absurdas, servem até mesmo para reforçar o tratamento distinto dado pelo legislador, dada a óbvia diversidade de delitos, abarcando objetos jurídicos bem diferentes" (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0002790-48.2021.8.26.0348, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, julgado em 17 de março de 2022).

"Apelação da Defesa. Tentativa de roubo com o emprego de arma de fogo. Provas suficientes à condenação. Réu detido em flagrante e reconhecido pessoalmente pela vítima. Negativa do acusado isolada do contexto probatório. Causa de aumento bem demonstrada. Laudo pericial suficiente a demonstrar a eficácia da arma de fogo apreendida. Inconstitucionalidade material da causa de aumento. Inocorrência. Patamar de exasperação adequado à maior gravidade da conduta, que expos a risco a integridade física da vítima. Pena-base exasperada ante os maus antecedentes do réu. O período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não afasta os maus antecedentes. Precedente do STF – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida. Pena elevada em 2/3 na terceira fase da dosimetria. Redução da pena em 1/2 pela tentativa. Patamar adequado ao "iter criminis" percorrido. Regime inicial fechado mantido. Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa. Recurso de apelação desprovido." (AP nº 1502466-58.2019.8.26.0540, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 18.12.20).

"ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (...). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI 13.654/2018. AFASTAMENTO. Proporcionalidade justificada pelo legislador, que procurou mesmo enrijecer o tratamento dado a crimes cometidos com o emprego de arma de fogo e explosivos. Exposição de motivos e precedente. Inconstitucionalidade afastada. Exposição de motivos e precedente. Inconstitucionalidade afastada. (...)" (AP nº 1502044-32.2018.8.26.0536, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 06.06.19) g.n.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Dosa-se as penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos réus no mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na fase intermediária, considerando que o réu Ezequiel é reincidente, majoro a sua pena em 1/6 (certidão de fl. 73 – proc. 7992-94.2007 c/c informações de fl. 79 – extinção da pena em 2021), atingindo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Em que pese a menoridade relativa de Moisés, a reprimenda não pode ser conduzida aquém do mínimo legal, consoante a Súmula 231 do STJ.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante logo após o roubo, em poder do bem subtraído, e buscou falsear a verdade, dizendo ter feito uso de um simulacro de arma de fogo, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel.

Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento

da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechado mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decisor, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP; Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADES DAS DROGAS, LOCAL DO CRIME, APREENSÃO DE DINHEIRO, CONFISSÃO DO RECORRENTE - INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA DADAS AS CONDIÇÕES DO FLAGRANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - BASES NO PISO. ADEQUADO O NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, UMA VEZ QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR PENA AQUÉM DO PISO - SÚMULA 231, DO C. STJ. - REDUTOR DESCABIDO NA ESPÉCIE - REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDOS - RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Criminal 1502209-62.2021.8.26.0540; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022) g.n.

"(...) Não era mesmo o caso de reconhecimento da confissão, já que parcial e não foi utilizada para convencimento do Juízo, que fundamentou: "não incidência da confissão em relação ao réu Rodrigo, uma vez que ao negar a participação dos corréus Wallace e Paulo, pretendeu ludibriar o Juízo, faltando com a verdade". Assim, a admissão parcial do fato não foi utilizada para formação de convicção do D. Juízo sentenciante, que se limitou a transcrever a versão dada pelos acusados, valendo-se, para se inclinar pela condenação, dos relatos da vítima, dos agentes policiais e da adolescente." (TJSP, Apelação Criminal nº 0013449-58.2017.8.26.0348, Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, j. 9 de março de 2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravamento regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Ôbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravamento regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se

verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, Dje, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

"No mais, quanto à atenuante da confissão espontânea, verifico que sua aplicação foi devidamente afastada, no caso, pelo Juízo sentenciante, "em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal", tendo o Magistrado pontuado que "a confissão de quem foi preso em flagrante, com imensa quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos para a preparação dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de fato prescindível para a condenação" (fl. 54).Nesse contexto, considerando que a confissão do Acusado não foi utilizada pelas instâncias ordinárias como reforço de fundamentação da condenação, não se aplica a Súmula n. 545 desta Corte Superior, segundo a qual "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal" (HC n. 668.711, Ministra Laurita Vaz, Dje de 21/03/2022).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 613736/RJ, QUINTA TURMA, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. em 30/03/2021, Dje 13/04/2021).

Além disso, não basta a confissão parcial para a incidência do disposto na alínea "d" do inciso III do art. 65 do Código Penal. Sobre o tema:

"É certo que para a obtenção do benefício não se admite a confissão parcial, e o acusado, interrogado em Juízo, negou o emprego de arma de fogo, comprometendo a verdade processual, tentando reduzir a gravidade de sua conduta, não merecendo então o benefício legal. TACRSP: "A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal" (RJDTACRIM 31/84)." (TJ/SP, Apelação Criminal 1501289-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 06/10/2020, Data de Registro: 06/10/2020 - grifo nosso).

"A confissão parcial não é o suficiente para reconhecer a atenuante porque

evidentemente objetivou algum benefício. A confissão espontânea tem que ser plena para valer como tal." (TJ/SP, Apelação nº 0052040-57,2010,8,26,0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Roberto Midolla, 02/06/2011).

Na terceira etapa, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.654 de 23 de abril de 2018, alinhando-me aos que entendem tratar o art. 68 do Código Penal de faculdade do magistrado. Possível, assim, desde que fundamentadamente, a incidência de mais de uma majorante. Nessa linha:

"Como se vê, na terceira fase da dosimetria, aplicou-se a fração mínima de 1/3 para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, ao argumento de que ocorreu prévio ajuste com divisão de atribuições específicas entre os agentes, o que foi fundamental para a expropriação patrimonial, e o patamar de 2/3 para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, por entender que o emprego de arma de fogo mostrou-se imprescindível para subjugar a vítima, notadamente porque estava na frente de sua residência e poderia ter se evadido para dentro do seu imóvel, caso não fosse ameaça com uso do artefato bélico. A utilização da arma, em via pública, eis que a vítima estava em frente a sua residência na hora dos fatos, gerou ainda mais riscos, tudo nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que faculta ao julgador aplicar cumulativamente as majorantes em concurso. Nesse mesmo sentido, é assente a jurisprudência deste STJ e também do STF, segundo a qual, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais." (STJ, HC 577363, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 28/05/2020 - grifo nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, Julgado em 15/08/2019, Dje 29/08/2019).

"Na derradeira etapa, pela majorante do concurso de agentes, a pena foi exasperada à razão de 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa. E, em razão da majorante do emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada à razão de 2/3 perfazendo 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, e 23 dias multa, no mínimo legal. Conforme mencionado acima, o cálculo da pena está correto, uma vez que as duas majorantes ora analisadas não se encontram mais previstas no mesmo parágrafo com a mesma fração de aumento, de modo que devem ser valoradas separadamente, por pura escolha do legislador com a referida alteração legislativa." (Apelação nº 1501168-40.2019.8.26.0537, Relatora Des. Ely Amioka, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 02/06/2020, Data de publicação: 02/06/2020 - grifo nosso).

"Na fase derradeira da dosimetria, incidiu, primeiro, o aumento mínimo (de um terço) pela majorante da comparsaria e, depois, o aumento de dois terços pelo emprego de arma de fogo. Não obstante o pleito da esforçada defesa, a incidência cumulativa dos aumentos devidos pelas duas majorantes se impõe, porque, ao revogar a causa de aumento do inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal e alocar tal causa no § 2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo previsão exclusiva para emprego de

arma de fogo , o legislador ordinário, através da Lei nº 13.654/2018, acabou por autorizar os aumentos sucessivos, pois o aumento devido pelo emprego de arma de fogo é fixo e não seria possível atender ao princípio da individualização da pena, se a censura estatal não pudesse ser devidamente dosada, sempre que presentes também uma ou mais causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157 aqui tratado. Tal solução, de resto, não conflita com a previsão constante do parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal, o qual estabelece que o juiz pode (faculdade) fazer incidir um só aumento em caso de concurso de majorantes, concluindo-se, a contrário sensu, que pode também fazer incidir mais de um aumento nessa fase dos cálculos. Nesse sentido, recente julgado desta Col. Corte de Justiça Estadual: Apelação nº 0047853-25.2018.8.26.0050, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1526276-77.2019.8.26.0050 - Voto nº 49783 8 Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Julg. em 01/04/2019." (APELAÇÃO CRIMINAL nº 1526276-77.2019.8.26.0050, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 19/05/2020, Data de publicação: 19/05/2020).

"Na terceira fase, a r. sentença procedeu a dois aumentos de pena, à luz da sistemática estabelecida pela Lei nº 13.654/18: (a) num primeiro momento, elevou a reprimenda em 1/3, em razão do concurso do agentes (artigo 157, par. 2º, II, do Código Penal); (b) na sequência, incrementou a sanção em 2/3, diante do emprego de arma de fogo (artigo 157, par. 2º-A, do Código Penal), chegando a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa. O procedimento não merece censura, porquanto de acordo com o novo modelo legal, que estabelece causas de aumento de pena diversas para o concurso de agente e emprego de arma de fogo. Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento. Dentro deste contexto, importa considerar (i) que a vítima Lucineide se lesionou ao cair da moto no momento da abordagem criminosa, e (iii) o veículo de Henrique foi recuperado destruído, de modo que houve considerável perda patrimonial; além disso, (iii) houve disparo de arma de fogo no crime praticado contra a vítima Pedro. Dados que incrementam a censurabilidade do comportamento, de sorte que a hipótese é de duplo aumento, tal como levado a efeito na r. sentença." (Apelação Criminal nº 1505281-28.2018.8.26.0228, Rel. Des. Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 03/06/2020).

Neste ponto, cumpre destacar que os bens subtraídos eram de alto valor (fl. 30) e o crime foi praticado com emprego de duas armas de fogo, em comparsaria com um terceiro indivíduo até então não identificado, em desfavor de uma única vítima, e, portanto, com relevante superioridade numérica. Desse modo, o problema diz com a proporcionalidade da reação penal ante a maior reprovação da conduta. À maior culpa, maior pena.

Assim, majoro a pena dos réus em 1/3, pelo concurso de agentes, totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa para o réu Ezequiel e 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa para o réu Moisés. Na sequência, tendo em vista o depoimento da vítima, no sentido de que os agentes portavam armas de fogo, necessário novo aumento de 2/3, totalizando 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa para o réu Ezequiel e 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa para o réu Moisés, penas que torno definitivas.

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

Os acusados deverão iniciar o cumprimento da pena sob o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. Além disso, o crime de roubo qualificado denota

uma periculosidade acentuada dos agentes, bem como evidente gravidade em concreto, cujo processo de ressocialização deve ser encetado no regime mais rigoroso. Bem por isso, a regra, no caso de roubo qualificado, é a fixação do regime inicial fechado em relação à sanção privativa de liberdade (STF, HC nº 74.301-3, rel. Min. Maurício Correa; TACRIM-SP, RJD TACRIM 16/143, 10/119). Não bastasse, o réu Ezequiel é reincidente.

Pelo mesmo motivo não se aplica nenhum benefício legal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu EZEQUIEL LOPES DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, às penas de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, sob regime penitenciário inicial fechado, e a pagar 23 dias-multa, no unitário mínimo, e o réu MOISÉS MARCOLINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, sob regime penitenciário inicial fechado, e a pagar 21 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no inciso II do parágrafo 2.º e no inciso I do parágrafo 2.º-A, ambos do art. 157 do Código Penal.

Denego aos condenados o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita (fl. 176). Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA